



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 144/15
מס' בקשה: 159/15

המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

המבקש: אברהם פריד - פריצי
התובע: מרחוב רבי עקיבא 20 ירושלים

- נ ג ד -

המשיבה: תמרה טמיר
הנתבעת: ע"י ב"כ עוה"ד עוז כהן
מרחוב יהודע בן נון 38 ירושלים

ה ח ל ט ה

המבקש עותר בבקשה דנן למתן צו זמני אשר יחייב את המשיבה לאפשר לו גישה חד פעמית לחלונות דירתו מצידם החיצוני לשם ביצוע עבודות ניקוי והרכבת רשתות יתושים.

טענות הצדדים בתמצית

1. לטענת המבקש המשיבה התקינה גדר בחצר המשותפת בבית ברחוב רבי עקיבא 20 ירושלים ומונעת בכך מעבר או גישה לתחזוקת חלונות דירתו מצידם החיצוני. למבקש זכות למעבר כמבוקש לשם תחזוקת דירתו, ללא כל קשר לשאלה (המצויה בבירור משפטי) בדבר זכותה של המשיבה להתקין את הגדר האמורה. הרשות הנדרשת הינה לצורך ביצוע תיקון מידי במועד שיתואם בין הצדדים. מתן הצו אינו גורע בדבר מזכויות הנתבעת ומאידך יאפשר השלמת עבודות שהופסקו במהלכן ואי השלמתן גורמת לנזקים הולכים ומתמשכים. המשיבה הסכימה לאפשר את הגישה אך לאחר מכן חזרה בה מהסכמה זו.
2. המשיבה טוענת כי מדובר בתובע סדרתי ומטריד, הבקשה נועדה לעקוף החלטות חלוטות ופסקי דין של ערכאות אחרות אשר כבר קבעו כי אין למבקש כל זכות מעבר בחצרה של המשיבה (המצויה החזקה ייחודית שלה), הבקשה הוגשה בשיהוי, מהווה כפל הליכים בנוגע לתובענה מקבילה שהוגשה ונדחתה בבית משפט השלום ומבוקש בה סעד זהה לזה המבוקש בהליך העיקרי. גם לגופם של דברים לא נדרשת גישה לטיפול בחלונות דירת המבקש אשר נפתחים כלפי פנים ומוגנים מבחוץ בסורגים. המשיבה מסכימה למעבר חד פעמי לשם החלפת החלונות הישנים אך לא לשם תחזוקתם השוטפת.
3. המבקש טוען בתשובה לתגובה כי פסק הדין בשלום עומד בפני הליכי ערעור ולפיכך אין מעשה ביידין או השתק פלוגתא. המבקש טוען עוד כי אף אם יקבע כי המשיבה זכאית להתקנת הגדר עדיין יש לאפשר לו זכות מעבר לתחזוקת רכושו הפרטי. לא ניתן לתחזק את החלונות אלא מבחוץ, כפי שעולה מנספחים שצורפו לכתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 144/15
מס' בקשה: 159/15

המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

דיון

4. בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות")).

ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.

ג. **מאזן הנוחות:** ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע.

ד. **שיקולים שביושר.** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).

5. בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אמר, פ"ד נו(1) 529; רע"א 10066/04 נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' פ.ס.ד. ספיר אנטרפרייז בע"מ, פ"ד נט(4) 700). עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ [פורסם באתר נבו]).

6. בנסיבות דנן עסקינן, כאמור, בבקשה למתן סעד זמני מסוג צו עשה אשר יחייב את המשיבה לאפשר גישה דרך החצר המצויה בשימוש ייחודי שלה. ההלכה קובעת כי צו כזה לא יינתן אלא במקרים יוצאי דופן: "קבלת סעד זמני מסוג צו-עשה זמני קשה יותר להשגה מאשר קבלת הסעד ההפוך (של צו מניעה זמני). בעוד שהסעד האחרון עומד בקריטריונים לעניין שמירת המצב הקיים, הרי שבמתן צו עשה זמני, יש, לכאורה, משום שינוי במצב הקיים" (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, (מהדורה תשיעית) בעמ' 527).

בבש"א (מחוזי-ת"א) 20818/03 מלכה שלמה נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, [פורסם בנבו], נקבע: "על אף שבית המשפט מוסמך לתת צו עשה זמני (ר' הגדרת "סעד זמני) בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984) יימנע בית המשפט בדרך כלל מנתינתו. צו כזה יינתן רק במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר הנזק לתובע הוא בלתי הפיך ושום פיצוי כספי לא יוכל לתקנו...".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 144/15
מס' בקשה: 159/15

המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ברע"א 5843/05 איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה נ' שרון דן השקעות בע"מ [פורסם בנבו], נקבע: "הלכה היא, כי על בית המשפט לנקוט משנה זהירות טרם שיצווה על צו עשה זמני המשנה את המצב הקיים, עוד לפני שניתנה ההכרעה הסופית בתובענה. צו עשה זמני המשנה מצב קיים ראוי שיינתן במקרים חריגים, אך כאשר נוכח בית המשפט כי התערבותו הינה חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכאשר הנזק שעלול להיגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם (ע"א 213/64 ברא"ז נ' נציב המים, פ"ד יח(3) 647, 653-654; וכן ראו רע"א 1868/98 סייג נ' המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי [פורסם בנבו])."

7. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לדחות את הבקשה.

8. ישנו קושי משמעותי בנוגע לעילת התביעה לכאורה בהליך דנן.

9. ראשית, מכתבי הטענות שהוגשו עולה כי בין הצדדים התנהל הליך בבית משפט השלום בתיק 15139-12-14 (להלן: "ההליך בשלום"). במסגרת הליך זה גם הוגשה על ידי המבקש דנן בקשה לסעד זמני לפיו ימנע מהמשיבה דנן לחסום את זכות המעבר של המבקש בשטח הגינה. במסגרת בקשה זו טען המבקש במפורש בנוגע לזכות גישה הנדרשת לחלונות דירתו ואשר בשל התקנת הגדר על ידי המשיבה נמנעת ממנו אפשרות פתיחתם, נעילתם וניקיונם (ר' סעיפים 8, 24, 26 ו-28 לנספח ב' לתגובה). במסגרת כתב התביעה בהליך בשלום עתר המבקש דנן למתן צו קבוע אשר יאפשר לו זכות מעבר בחצר, לרבות בנוגע לתחזוקת החלונות (ר' למשל סעיפים 7-8, 12 ו-30 לנספח ג' לתגובה).

יוצא, אם כן, כי מדובר בהליך בו התבקש סעד זהה לזה המבוקש במסגרת ההליך דנן. ויודגש, אף שבהליך בשלום התבקש סעד רחב יותר, שאינו עוסק רק בגישה לחלונות הדירה, הרי שמניה וביה סעד של גישה לחצר כולל גם גישה לאותם החלונות, ובפרט כאשר המבקש דנן התייחס במפורש לחלונות אלו במסגרת כתבי הטענות מטעמו בהליך בשלום כאמור.

מדובר, למעשה, בתובענה ובקשה למתן סעד זמני חוזרים במסגרתם מבקשים לקבל את אותם הסעדים ועל יסוד אותן העילות. על פני הדברים לא ניתן לעשות כן מכוח הכלל בדבר מעשה בי-דין מסוג השתק עילה, ודאי כאשר ההליך בשלום הסתיים בפסק דין (ר' בהרחבה בתיק 284/12 (ת"א) ציטורין נ' הדדי (פורסם באתר משרד המשפטים)).

ויודגש, אף שתלוי ועומד ערעור בגין פסק הדין בהליך בשלום אין הדבר מביא לביטול ההליך בכללותו, ודאי שאין בהליך ערעור זה כדי לבטל את עצם קיומו של ההליך בשלום. אין הדבר גם מקנה אפשרות בהתאם להוראות הדין להגיש תובענה זהה בפני ערכאה אחרת.

10. במיוחד אמורים הדברים כאשר בשלב זה עסקינן בבקשה לסעד זמני וכאשר בית המשפט המחוזי, במסגרת רע"א 4753-02-15, דן בטענות המבקש בהקשר זה, לרבות טענות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 144/15
מס' בקשה: 159/15

המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מפורשות לעניין החלונות ותחזוקתם ודחה את הערעור על החלטת בית משפט השלום שלא ליתן בידי המבקש סעד זמני זהה לזה המבוקש כאן (ר' סעיפים 6 ו-7 להחלטה מיום 24.02.15). על המבקש היה למצות את הליכי הערעור על ההחלטה האמורה חלף נקיטת הליכים חדשים מקבילים וזהים בפני ערכאה אחרת, כפי שעשה בבקשה דנן.

11. שנית, אף אם היינו רואים בהליך בשלום כהליך "פתוח" לאור הליכי הערעור, הרי שממילא אין בשלב זה בידי המבקש עילת תביעה לכאורה לניהול ההליך בפני.

בהתאם לעיקרון המכונה "הליך תלוי ועומד" (Lis Alibi Pendens) מוסמך בית המשפט להעמיד את הדיון בהליך אחד כל עוד תלוי ועומד הליך אחר בין אותם בעלי דין- "זוהי סמכות שבשיקול דעת והיא הופעלה לא אחת תוך שקילת יעילות הדיון, יעילות המערכת השיפוטית, חסכון במשאבי זמן והוצאות, מניעת הכרעות סותרות, נוחות בעלי הדין, הכרעה מהירה, מאזן הנוחות וכיו"ב. אם נכונים הדברים לגבי הליכים רגילים, קל וחומר כך לגבי הליכי תובענות ייצוגיות לרבות בקשות לאישורן, באשר לא ראוי משום בחינה לאפשר ניהול מספר הליכים כאלה בו זמנית בשאלות דומות, בעילות דומות ובעניינים דומים שתשתיתם זהה. הדברים נכונים לא רק כאשר מדובר בין אותם צדדים בשני ההליכים, אלא גם כאשר הצדדים אינם אותם צדדים אלא שהעניינים דומים, העילות זהות והאינטרס זהה" (רע"א 3765/01 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אלכסנדר קפלן (פורסם בנבו)).

על אחת כמה וכמה נכונים הדברים כאשר, כפי שאמורים הדברים בנסיבות דנן, **מדובר בהליכים זהים בין אותם צדדים** (ת"א (י-ם) 2002/00 אליאס ג'ייקוב נ' חברת אלי יוחנן מהנדסים - הנדסה ובניין בע"מ (פורסם בנבו)).

12. שלישית, לא עלה בידי המבקש לשכנע מדוע לא ניתן לתחזק את החלונות מתוך דירתו. ודאי אמורים הדברים בנוגע לחלונות המתועדים בנספח ד' לתגובה אשר נפתחים פנימה לתוך דירת המבקש ומוגנים בסורגים חיצוניים. אולם, גם בנוגע לחלונות המתועדים בנספח ב' לכתב התביעה לא ברור מדוע לא ניתן לתחזקם מתוך הדירה, לרבות, באמצעות התקנת חלונות או כל חומר אחר בצידם הפנימי של הסורגים ולא באופן חריג מצידם החיצוני.

13. די באמור להביא לדחיית הבקשה. אולם, גם בשיקולים שבמאזן הנוחות ושיקולים שביושר יש להצדיק את דחיית הבקשה.

14. ראשית, שעה שבקשת המבקש לסעד זמני במסגרת ההליך בשלום נדחתה (לרבות על ידי בית המשפט המחוזי במסגרת בר"ע שהוגשה) מאזן הנוחות נוטה לטובתה של המשיבה שלא תוטל שוב בפני ערכאה אחרת בבקשה זהה לכזו שנדונה והוכרעה. ודאי אמורים הדברים כאשר המבקש איננו מצביע בהליך דנן על כל עילת תביעה שונה או שינוי נסיבות כלשהו וחוזר, למעשה, על בקשתו הקודמת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 144/15
מס' בקשה: 159/15

המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

15. שנית, נכון לעת הזו בידי המשיבה הכרעה משפטית לפיה הינה בעלת זכות שימוש ייחודית בחצר. לא ניתן באמצעות בקשה למתן סעד זמני להביא לפגיעה עקיפה, אף רגעית, בזכות מוכרת זו.

16. שלישית, לא עלה בידי המבקש להראות כי אי הענות לבקשתו תביא לפגיעה משמעותית בזכויותיו או לנזק כלשהו אשר יש בהם להצדיק פגיעה זמנית בזכויות המשיבה.

כאמור, המבקש יכול לתחזק את החלונות ולהתקין חדשים תחתם מתוך דירתו.

זאת ועוד. לאור טיעוני המבקש הרי שמעבר חד פעמי אין בו די בנסיבות לתחזוקה מלאה של החלונות ולפיכך אין בהיענות לבקשה (לגישה חד פעמית) כדי לסייע בידו באופן משמעותי.

וידגש, לשם החלפת החלונות (להבדיל מתחזוקתם שעל פי טענת המבקש עצמו מחייבת גישה משמעותית עד כדי יומיומית) מסכימה המשיבה לאפשר גישה חד פעמית (ר' סעיף 22 לתגובה). זהו למעשה, בנסיבות המשפטיות הקיימות, הסעד הנכון לפתרון נזקיו הנטענים של המבקש.

17. רביעית, על פני הדברים הבקשה מוגשת בשיהוי ניכר - מניעת הגישה קיימת כבר חודשים רבים וכך גם הצורך להביא לתחזוקת החלונות לכאורה, מידי יום ביומו. לראיה, המבקש אף נקט בהליכים בפני ערכאות מוסמכות, לרבות, בקשה לסעד זמני בהקשר האמור. אף על פי כן הבקשה בפני הוגשה רק עתה (לאחר דחיית בקשה זהה על ידי ערכאות מוסמכות אחרות כאמור) ואף לא בצוותא עם הגשת התביעה העיקרית. אין כל הסבר לשיהוי המשמעותי כאמור בהגשת הבקשה.

18. לכל זאת יש להוסיף את העובדה כי הסעד הזמני המבוקש הינו זהה, למעשה, לסעד העיקרי המבוקש במסגרת ההליך – מתן זכות גישה לשם תחזוקת דירת הנתבע, ובפרט, חלונות דירתו (בין אם גישה חד פעמית ובין אם קבועה). עקב כך, קבלת הבקשה עלולה, במידה רבה, לייתר את המשך הדיון בהליך העיקרי.

אומנם, אין בעובדה זו כשלעצמה כדי לשלול מתן סעד זמני כשזה נדרש, אך שיקול זה מצטרף לשיקולים האחרים כאמור לעיל אשר מטילים את כף מאזן הנוחות ושיקולי היגיון לכיוון דחיית הבקשה, ודאי לאור הקושי המשמעותי בנוגע לעילת התביעה לכאורה (רע"א 4196/93 שפ"ע בר נ' שפ"ע מסעדות ייצור ושיווק פד"י מז(5) 165).

19. וידגש, בקשה לסעד זמני לא נועדה כדי להביא לקידום בירור ההליך העיקרי וזוהי, למעשה, כל תכליתה של הבקשה דנן, שלא הוגשה אלא לאור לוחות הזמנים שנקבעו לבירור ההליך (ר' במפורש בפסקה שניה בעמוד 2 לבקשה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 144/15
מס' בקשה: 159/15

המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

סיכום

20. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.

21. בהתאם להסכמת המשיבה כאמור לעיל עומדת לזכות המבקש האפשרות לתאם עם המשיבה, באופן חד פעמי, מועד למעבר בחצר לשם החלפת חלונות דירתו בלבד.

22. המבקש ישלם למשיבה את הוצאות הבקשה בסך של 1,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה בלישכתי ביום ט' סיון תשע"ה, 27 מאי 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין